

検察官は、ハンマーを凶器とする傷害被告事件の証拠として、犯行を目撃したWの検察官に対する供述調書及び犯行に使用されたとされるハンマーの証拠調べを請求した。この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. ハンマーには伝聞法則は適用されないから、裁判所は、弁護人の意見を聴かずに、ハンマーを証拠として採用するか否かを決定することができる。

イ. Wの証人尋問が行われ、刑事訴訟法第321条第1項第2号後段の規定により、Wの証言と相反する供述が録取されたWの検察官に対する供述調書の証拠調べが請求された場合、裁判所は、証拠能力の有無を判断するためであっても、その採用決定をする前に、同供述調書を見ることはできない。

ウ. Wの証人尋問が行われ、Wの証言と相反する供述が録取されたWの検察官に対する供述調書が刑事訴訟法第321条第1項第2号後段の規定により証拠として採用された場合であっても、Wの証言は証拠能力を有する。

エ. ハンマーの証拠調べの方法は、ハンマーを裁判所と訴訟関係人が認識できる状態にすることである。

オ. ハンマーがいまだ証拠として採用されていない段階でWの証人尋問が行われた場合、Wに対するハンマーを示しての尋問が許されることはない。

1. ア イ 2. イ オ 3. ウ エ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 誤っている

ハンマーは非供述証拠であり、伝聞法則は適用されない。よって、前段は正しい。しかし、裁判所は、請求に基づく証拠決定をする場合には相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない（規則 190 条 2 項）。よって、本件では検察官によりハンマーの証拠調べ請求がなされているため、裁判所は、相手方又は弁護人の意見を聴かなければならない。なお、被告人が出頭しないでも証拠調べを行うことができる公判期日に被告人及び弁護人が出頭していないときは、これらの者の意見を聴かないで証拠決定できるが（規則 190 条 3 項）、本件は傷害事件で、被告人の出頭を要するので（284 条、285 条 2 項、286 条、刑法 204 条参照）、規則 190 条 3 項の適用はない。したがって、本記述は、裁判所は、弁護人の意見を聴かずに、ハンマーを証拠として採用するか否かを決定することができるとしている点で、誤っている。

イ 誤っている

検察官面前調書が、321 条 1 項 2 号後段の規定により、証拠調べ請求された場合には、裁判所はその証拠能力を判断するために、特信情況の認定を行う必要がある。そして、その認定に関しては、検察官面前調書の記載内容を考慮することができ、供述の対比によって日時経過による記憶の著しい減退が生じたかどうか、前の供述の方が理路整然としており、筋道立っているかどうか、などが重要な判断資料となる。判例も「刑訴 321 条 1 項 2 号は、伝聞証拠排斥に関する同 320 条の例外規定の一つであって、このような供述調書を証拠とする必要性和その証拠について反対尋問を経ないでも充分の信用性ある情況の存在をその理由とするものである。そして証人が検察官の面前調書と異った供述をしたことによりその必要性は充たされるし、また必ずしも外部的な特別の事情でなくても、その供述の内容自体によってそれが信用性ある情況の存在を推知せしめる事由となると解すべきものである。」としている（最判昭 30.1.11、百選 A37 事件）。よって、裁判所は、W の検察官に対する供述調書の証拠能力を判断するために、当該供述調書の記載内容を考慮することができるから、当該調書を見ることができる（規則 192 条）。したがって、本記述は、裁判所は採用決定する前に、供述調書を見ることはできないとしている点で、誤っている。

ウ 正しい

検察官面前調書が 321 条 1 項 2 号後段の規定により、証拠採用された場合には、「公判準備若しくは公判期日における供述」は、検察官面前調書と「相反するか若しくは実質的に異なっ」ており、かつ、当該検察官面前調書より、その供述内容の信用性が低い場合であるから、当該「公判準備若しくは公判期日における供述」の証拠能力は、その反射の効果として、何らかの影響を受けるとも思われる。しかし、証拠能力の有無は法律によって定められており、例えば、被告人以外の者の公判廷での直接供述については、法は特に証拠能力を制限する規定を設けていない。そのため、適式に宣誓した証人の虚偽の証言にも証拠能力はあるとされている。また、321 条 1 項 2 号も、当該規定によって証拠採用された検察官面前調書の証拠能力を肯定するにとどまる。そうだとすれば、本問でも、W の証言の証拠能力は否定されない。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

306条1項本文。同条項本文は「検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示さなければならない。」としている。同条は、証拠物に対する証拠調べの方式について規定したものであり、証拠物においては、証拠としての価値を持つのはその存在又は状態であるから、それを公判廷に顕出する証拠調べの方式は展示であることを明らかにしたものであると解されている。そして、展示の方法は、裁判所及び訴訟関係人が証拠物の存在又は状態を明確に認識し得る程度になされる必要があるとされている。よって、検察官は、証拠調べ請求をしたハンマーを裁判所と訴訟関係人が明確に認識できる状態にする必要がある。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

規則199条の10第1項は「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。」と規定し、2項本文は「前項の書面又は物が証拠調べを終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。」として、証人尋問においては、証拠調べが終了していない物証を証人に示すことができるが、その場合には、事前に相手方に当該物証を閲覧する機会を与えなければならないことを規定している。また、規則199条の11も、記憶喚起のための物の展示を認めており、この場合には199条の10第2項を準用している。したがって、本記述は、Wに対するハンマーを示しての尋問が許されることはないとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はウとエであり、したがって、正解は肢3となる。

